

1529734-82.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... a condenação dos réus pelo crime de tráfico, nos termos da denúncia. Requereu fixação da pena-base acima do mínimo para Carlos e fixação de regime semiaberto.

O Defensor constituído postulou a desclassificação da conduta dos réus, argumentando que não há provas quanto à prática de tráfico pelos réus, devendo prevalecer a versão dos réus. Subsidiariamente, requereu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529734-82.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529734-82.2021.8.26.0228, c. 51/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2335868/2021 - DEL.SEC.3ª OESTE, 21871513 - DEL.SEC.3ª OESTE, 316/21/300 - DEL.SEC.3ª OESTE, 2335868 - DEL.SEC.3ª OESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO PINHEIRO SOUSA DE JESUS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

WELLERSON ROGER MIRANDA e CARLOS EDUARDO PINHEIRO SOUSA DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia a 09 de dezembro de 2.021, por volta de 15h30min, na Rua Cláudio nº 59, casa de cima, Lapa, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso, caracterizado pelo vínculo subjetivo e unidade de

desígnios, para fins de entrega e comercialização a terceiros pessoas, trazia consigo (Wellerson), aproximadamente 292,5g (duzentos e noventa e dois gramas e cinco decigramas) da droga Tetrahydrocannabinol (THC), na forma de "haxixe", acondicionados na forma de 03 (três) plaquetas (formato de "tijolos"), envoltas em invólucros plásticos, e, guardava e tinha em depósito (Carlos) e 244,2g (duzentos e quarenta e quatro gramas e quatro decigramas) da droga Tetrahydrocannabinol (THC), na forma de "haxixe", acondicionados em 02 (dois) invólucros plásticos na forma de "tijolos", aproximadamente 5,8g (cinco gramas e oito decigramas) da droga Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida por "maconha", acondicionados em 04 (quatro) trouxinhas de plástico, aproximadamente 1g (um grama) da droga Tenanfetamina (MDA), popularmente conhecida por "ecstasy", na forma de 05 (cinco) comprimidos, aproximadamente 1,3g (um grama e três decigramas) da droga Metilenodioximetanfetamina (MDMA), popularmente conhecida por "ecstasy", acondicionados em 04 (quatro) comprimidos, aproximadamente 1,7g (um grama e sete decigramas) da droga cocaína, acondicionados em 04 (quatro) papelotes, aproximadamente 806,3g (oitocentos e seis gramas e três decigramas) da droga Tetrahydrocannabinol (THC), acondicionados em 24 (vinte e quatro) pacotes com as inscrições "Stoney Poppers", contendo referida substância ilícita, em formato de balas de goma, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

A denúncia foi oferecida em 14 de janeiro de 2022. Em 17 de janeiro de 2022 houve a determinação para a notificação dos réus.

Os réus foram notificados (Carlos - fls. 274 e Wellerson - fls. 276) e ofertaram defesa preliminar às fls. 286/289. Foram citados às fls. 315 e 317.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa, sendo a seguir os réus interrogados. Não foram requeridas diligências pelas partes. Em alegações finais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação dos réus pelo crime de tráfico, nos termos da denúncia. Requereu fixação da pena-base acima do mínimo para Carlos e fixação de regime semiaberto.

O Defensor constituído postulou a desclassificação da conduta dos réus, argumentando que não há provas quanto à prática de tráfico pelos réus, devendo prevalecer a versão dos réus. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, atenuante da confissão, redutor, regime aberto ou semiaberto, com detração.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os policiais civis narraram que receberam denúncia anônima dando conta de estaria ocorrendo o tráfico de droga no local dos fatos, cujo endereço foi informado exatamente. O policial Ricardo, que recebeu a denúncia, disse que o denunciante passou as características físicas do suposto traficante. Passaram a realizar campana no local, por cerca de uma semana, período no qual observaram o réu Carlos, cujo nome ainda não era conhecido, entrando e saindo diversas vezes. Certa vez ele chegou a ir até o metrô e encontrou uma pessoa na catraca, mas decidiram não realizar a abordagem em tal dia. Foram feitos registros de tais situações, mas não foi feita a juntada, segundo Ricardo, porque entenderam que não havia relevância quanto a tais registros. No dia dos fatos, iniciaram a campana e observaram quando Wellerson chegou ao local em um carro, que ficou ali aguardando. O réu Carlos abriu o portão para entrada de Wellerson, que ali ficou por cerca de 30/40 minutos. Quando Wellerson deixou o local e se dirigiu para o veículo que o aguardava foi abordado. Na mochila que ele carregava encontraram três tijolos de haxixe. Ele informou que havia adquirido a droga no imóvel que era objeto de investigação pelos policiais, esclarecendo que o vendedor residiria na parte de cima do imóvel. Quando realizavam a abordagem dele, perceberam que uma moradora deixava o local, motivo pelo qual Ricardo dela se aproximou, ficando Adolfo na contenção de Wellerson e do motorista de aplicativo. Ricardo conversou com a moradora e explicou a situação, sendo que ela confirmou que Carlos residia no local e que já havia sentido cheiro de drogas. Ela franqueou a entrada da equipe no local. Ricardo fez uma verificação prévia, chamando seu colega para entrar no local, o que foi feito. O imóvel estava com a porta aberta, sendo que encontraram Carlos na sala, deitado no sofá. Parecia

que ele tinha feito uso de drogas. Em revista no local, encontraram no armário do quarto ocupado por Carlos diversos tipos de droga. Também havia dinheiro no local, mas não se recordavam a quantidade, tampouco se estava em notas trocadas. Carlos disse que estava passando por dificuldades financeiras, que seu restaurante havia fechado durante a pandemia, e que ele havia usado os recursos que tinha para vender drogas e tentar ganhar dinheiro rapidamente. O motorista de Uber apresentou o celular dele, no qual constataram que havia uma corrida em aberto. Ele disse que não conhecia Wellerson anteriormente. Ele foi levado ao Distrito Policial, mas a autoridade policial decidiu liberá-lo sem ser ouvido. A vizinha que franqueou a entrada não foi levado ao Distrito Policial.

Os réus negaram a acusação que lhes é feita. Disseram que se conhecem de bares há quase dois anos e que decidiram comprar drogas juntos, para conseguir melhor valor. Compraram o haxixe no dia anterior à abordagem, sendo que Wellerson pagou R\$ 1.500 e Carlos R\$ 1.000. Toda a droga foi levada para a casa de Carlos, pois Wellerson teria de retornar ao trabalho. Carlos disse que comprou o restante da droga no próprio dia em que foi abordado, no mesmo local, sendo que não tinha comprado no dia anterior, porque o traficante não tinha o que queria. Pelo restante da droga pagou cerca de R\$ 650. O dinheiro que estava em sua casa era para pagamento do aluguel, valor que sacou de sua conta alguns dias antes.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu Carlos apenas, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, prontas para a fracionamento e, posterior, entrega a terceiros; campana efetuada pelos policiais civis que constataram movimentação suspeita relacionada à traficância em dias diversos, conforme depoimento dos policiais; ausência de demonstração que a droga destinava-se para consumo próprio, sendo que a variedade de drogas e a quantidade delas que estavam dentro do imóvel são absolutamente incompatíveis com a condição de usuário; localização de quantia expressiva de dinheiro no imóvel cuja origem lícita não foi comprovada; incompatibilidade entre a quantidade de drogas e a quantidade de dinheiro com a situação financeira do réu, sendo que na fase policial o réu Carlos afirmou estar desempregado e na presente data disse que trabalha informalmente cozinhando em eventos. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câmara Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Anoto não haver nenhuma ilegalidade na diligência realizada pelos policiais no imóvel, na medida em que as imagens fornecidas pela combativa defesa (fls. 172) deixam claro não ter havido nenhuma violação de domicílio a fim de macular o flagrante. Neste sentido, analisando-se detalhadamente as imagens é possível visualizar uma mulher vestida de macacão rosa, chegando ao imóvel, em posse de chaves e abrindo o portão para ali entrar. Pouco tempo depois é possível ver alguém abrindo o portão para o um indivíduo vestido de azul sair do imóvel carregando uma mochila nas costas. Referida pessoa atravessa a rua e logo muda de direção passando a descê-la rumo a um automóvel estacionado em frente a um veículo Ka preto, ocasião em que é abordado pelos policiais civis. Após referido indivíduo ser abordado, o qual, posteriormente, mais ao final do vídeo, retorna algemado, possibilitando sua segura identificação como sendo réu Wellerson, é possível observar a mulher de rosa, novamente, abrir o portão com suas chaves e sair do imóvel trancando-o, sendo, imediatamente, abordada por um dos policiais civis, que chega sem empunhar nenhuma arma de fogo, apenas ostentando o brasão da polícia civil em seu peito a

fim de permitir sua identificação.

Após breve conversa entre eles, nitidamente, a mulher autoriza a entrada do policial no imóvel, destrancando o portão com suas chaves e, ainda, é possível ver que a mulher se detém no portão, por alguns instantes, gesticulando a fim de explicar ao policial como ele conseguiria chegar ao andar superior no qual reside o corréu Carlos e onde mais entorpecentes foram localizados.

Assim, não há que se falar em violação de domicílio eis que claramente presentes sérios indícios sobre a ocorrência de um flagrante no local posto que o réu Wellerson foi abordado e entorpecentes foram encontrados na mochila que carregava e, some-se a isto, uma mulher com as chaves do imóvel, voluntariamente, abriu o portão autorizando a entrada do policial no local de modo que inexistente qualquer forma de coação ou abuso de autoridade por parte dos policiais no caso em apreço estando o flagrante dentro dos limites legais.

Em se tratando de crime de múltipla conduta, o depósito da droga configura o delito, de maneira que não há ofensa à inviolabilidade de domicílio pelo ingresso dos policiais no local.

Conforme se verifica por decisão do STJ, este meio de prova é legítimo, eis o julgado:

RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas as que delas decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional. 3. Recurso especial não provido. (Resp 1722676 / BA, RECURSO ESPECIAL 2017/0209745-7, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 23/08/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 04/09/2018).

E ainda:

Ementa: Constitucional e penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Posse de arma de fogo de uso permitido e tráfico de entorpecentes - arts. 12 da Lei n. 10.826/2003 e 33 da Lei n. 11.343/2006. Condenação em segundo grau. Trânsito em julgado. Ilícitude da prova, tendo em conta a inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal). Relativização da tutela constitucional em caso de flagrante, para prestar socorro ou por determinação judicial. Ocorrência, in casu, de flagrante. Não cabimento do writ como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de flagrante constrangimento ilegal. Inocorrência, in casu. 1. A norma que tutela a inviolabilidade de domicílio, inserta no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, não é absoluta, cedendo "... em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" (HC74127, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 13/06/1997, e RHC 86082, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 22/08/2008). 2. In casu, consta na denúncia que "No dezessete de outubro, do ano de dois mil e oito, cerca das vinte e uma horas e trinta minutos, o denunciado foi preso em estado de flagrância [GRIFEI] por policiais militares lotados no 25º BPM, porque, com vontade livre e consciente, direcionada à prática do injusto, tinha em depósito e guardada, na sua residência, localizada na Rua da Capivaras, Travessa 07, nº 13 - Unamar, nesta cidade, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entregar a consumo ou fornecer, ainda que gratuitamente, aos usuários, certa quantidade de

drogas capazes de determinar dependência física ou psíquica, denominadas Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, e ainda, Cloridrato de Cocaína, popularmente conhecida como cocaína, destinadas ao efetivo exercício do nefando comércio das drogas da morte, além do Revólver, sem marca, calibre 38, com numeração raspada, regularmente municiado e em condições de ser utilizado na prática de ilícito penal, conforme noticiam o auto de apresentação e apreensão à fl. 04 e laudos toxicológico à fl. 06 e pericial de potencialidade ofensiva da arma, que será juntado oportunamente, cujas peças técnicas evidenciam a materialidade delitiva". Por esses fatos, o paciente foi condenado, em 04/08/2010, pelo Tribunal de Justiça, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e (20) vinte dias como incurso nos arts. 12 da Lei n. 10.826/03 e 33 da Lei n. 11.343/06 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de entorpecentes)". 3. Destarte, o acesso de policiais à residência do paciente, em decorrência do flagrante delito, não tem a aptidão de eivar de ilicitude as provas ali colhidas, in casu, maconha, cocaína e arma de fogo municada, sobrevivendo acórdão que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e (20) vinte dias pelos crimes tipificados nos arts. 12 da Lei n. 10.826/03 e 33 da Lei n. 11.343/06 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de entorpecentes). 4. O Habeas corpus não é admissível como sucedâneo de revisão criminal, ressalvadas as hipóteses de flagrante constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos (RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011; HC 107839/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 7/6/2011; HC 104462/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 27/6/2011; HC 102473/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 29/4/2011; HC 98681/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 15/4/2011). 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 117159, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).

Em se tratando de crime permanente, havendo fundada suspeita de sua ocorrência, decorrente de elementos colhidos de forma concreta pelos agentes, o ingresso em domicílio sem prévia autorização judicial mostra-se viável e não macula a prova que venha a ser colhida no decorrer da diligência policial. Assim, decidiu o C. STF, ao proferir decisão no RE 603616/RO, julgado em regime de repercussão geral.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

"É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e comprovando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Desembargador Canguçu de Almeida, em 07/10/91 - 2ª Câmara Criminal do T.J.S.P.).

Observo que pequenas contradições, não essenciais aos fatos, apenas ratificam a veracidade de seus depoimentos, pois indicam de forma clara que não houve prévio ajuste sobre a versão que deveria ser ofertada, baseando-se seus relatos exclusivamente na memória que têm do dia dos fatos.

A materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 147/150 que atestou os efeitos tóxicos das substâncias apreendidas, além do auto de exibição e apreensão (fls. 08/09).

Tais elementos autorizam, portanto, o acolhimento da pretensão punitiva estatal em relação a Carlos.

Com relação a Wellerson, no entanto, entende-se de forma diversa. Com efeito, em poder dele foi encontrado apenas um tipo de droga, em quantidade que, por si só, não indica a prática de tráfico. Não há outros elementos que indiquem que ele pegou a droga com Carlos para revende-la, mas não para consumi-la. Os policiais narraram que aquela foi a primeira vez que o viam no local. Com ele não tinha qualquer dinheiro ou outros apetrechos que possam ser relacionados ao tráfico. Ele disse aos policiais, desde o início, que a droga era para seu consumo próprio. Os policiais narraram que ele disse que era pedreiro ou marceneiro e que suas vestes indicavam a veracidade de tal afirmação, pois estavam sujas, sendo que dentro de sua mochila havia ferramentas relacionadas a tal tipo de trabalho. Assim, afora a quantidade elevada, nada há a indicar que a droga destinava-se para venda, de modo que inexistem outros elementos que possam justificar o acolhimento da pretensão da forma como lançada na denúncia, devendo sua conduta ser desclassificada. Com efeito, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 prescreve que: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". Na dicção legal, portanto, a quantidade da substância entorpecente apreendida constitui apenas um dos elementos eleitos pela norma para a classificação da conduta do agente, de forma que tudo dependerá das circunstâncias do caso concreto, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial adotado, confira-se: "TÓXICO - Tráfico - Desclassificação - Uso próprio - Admissibilidade - Dúvida acerca do comércio ilícito - Réu sem registro de antecedentes que trabalha e ajuda a mãe - Grande quantidade de droga - Insuficiência para a caracterização do tráfico - Recurso parcialmente provido." (TJSP - Apelação Criminal nº 167.762-3 - Moji-Guaçu - CCRIM 6 - Rel. Fanganiello Maierovitch). Na lição de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ainda, "os aspectos subjetivos de uma conduta, porém, só podem ser aferidos por circunstâncias objetivas, que o artigo enumera com a finalidade de orientação do juiz. Na verdade, o dispositivo nada acrescenta, mas tem uma intenção que o justifica, qual seja, a de chamar a atenção do magistrado para que aprecie todas as circunstâncias do crime e não apenas a quantidade da droga apreendida, critério simplista e único considerado na vigência do art. 281 do Código Penal antes do Decreto-Lei n. 385. A quantidade da droga, não se nega, é fator importante, mas não pode ser exclusivo, devendo, pois, o juiz apreciar as demais circunstâncias que envolvem o delito, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (in Lei de Drogas Anotada, Editora Saraiva, 2007, página 48).

Assim, necessária a desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Forçosa, destarte, a condenação do réu Carlos e a desclassificação da conduta de Wellerson nos termos acima expostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

CARLOS

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a despeito da natureza nociva de um dos entorpecentes encontrados em poder do réu (cocaína), entende-se que a quantidade era insuficiente para representar maior mácula ao bem jurídico tutelado. Assim, a pena-base é ora fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas para ambos réus.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa

de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes dos acusados que não se dediquem às atividades criminosas e não integrem organização criminosa, reduzo as penas no máximo (porque a quantidade não era excessiva a justificar redução inferior), ficando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Reputa-se que apenas a quantidade e a variedade das drogas encontradas em poder do réu não justifiquem a não incidência da causa de diminuição de pena, na medida que nada há nos autos de concreto a demonstrar vínculo do réu com o crime organizado. Com efeito, a quantidade com ele encontrada não é exorbitante, a demonstrar, por si só, relação com criminosos de maior poder econômico e, portanto, vinculados ao crime organizado.

Tendo em vista sua primariedade técnica, o quantum de pena aplicado e a quantidade não exorbitante de drogas apreendidas em seu poder nestes autos, fixo o regime aberto como inicial para cumprimento da pena.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

WELLERSON

Tratando-se de réu primário, cabível a aplicação da pena de advertência com exclusividade, não se vislumbrando a necessidade ou adequação de que pena mais severa seja aplicada.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO PINHEIRO SOUSA DE JESUS, por infração ao artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme abaixo determinado. Outrossim, CONDENO o réu WELLERSON ROGER MIRANDA como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de advertência.

Observo, no entanto, que o réu Wellerson permaneceu preso por este feito desde a data dos fatos até a presente data. Reputo que a permanência no cárcere sirva, por si só, de advertência ao réu sobre os malefícios da droga, que restringiu sua liberdade por período considerável, sendo absolutamente desnecessário que o réu seja admoestado verbalmente.

Por isso, com fulcro no artigo 42 do Código Penal, considero cumprida a pena ora imposta ao réu e, em consequência, JULGO EXTINTA a punibilidade de WELLERSON ROGER MIRANDA.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com relação a Carlos, a despeito de o entendimento pessoal desta magistrada ser no sentido da total incompatibilidade entre o delito de tráfico e a substituição por pena restritiva de direito, após reiteradas reformas às sentenças proferidas pelas instâncias superiores, curvo-me ao entendimento do E. STJ no sentido de não haver impossibilidade de se conceder tal benefício ao pequeno traficante, beneficiado com a causa de diminuição de pena. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções (não podendo ser entidade educacional ou de saúde), bem como por prestação pecuniária no valor correspondente

a 01 (um) salário(s) mínimo(s), também em favor de entidade a ser indicada pela Vara das Execuções.

Ausentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, diante do regime ora fixado e da substituição da pena privativa de liberdade, defiro ao réu Carlos o direito de recorrer da presente sentença em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, lancem-se os seus nomes no rol dos culpados e expeçam-se guias de recolhimento definitivas.

Custas na forma da lei,.

Oficie-se para que se proceda à incineração dos entorpecentes apreendidos independentemente de trânsito em julgado.

Tendo em vista que o dinheiro encontrado com o réu Carlos não teve sua origem lícita demonstrada nos autos, estando nitidamente atrelado ao tráfico de entorpecentes, em razão da sentença condenatória ora proferida, determino seu perdimento nos termos da lei. Oportunamente, oficie-se para transferência do valor e, nos termos do COMUNICADO CG Nº. 805/2019 da E. Corregedoria Geral da Justiça, oficie-se para comunicação sobre o perdimento, encaminhando-se o ofício para a Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Ministério da Justiça e Segurança Pública, Edifício Sede, sala 208, Brasília, Distrito Federal, CEP: 070064-900.

Com relação às lesões apontadas nos laudos IML (Wellerson fls. 95 e Carlos fls. 101), desnecessária adoção de qualquer providência adicional eis que a apuração perante a Corregedoria da Polícia Civil já foi determinada às fls. 74 – item 07 e devidamente comunicada às fls. 96/97.

P.R.I.

São Paulo, 31 de março de 2021.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA